

0000016-18.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000016-18.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000016-18.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 863/2021 - Delegacia de Polícia de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sávio Felipe Mendes Sousa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

SAVIO FELIPE MENDES SOUSA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j" (calamidade pública) do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 10 de abril de 2021, por volta das 13h39min, na Rua Carminé Maimone, 243, Parque Residencial João Ometto, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 conforme Decreto Estadual nº 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020, o acusado, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame toxicológico).

Ao que se apurou, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID 19, na ocasião supramencionada, o denunciado trazia consigo drogas para fins de comercialização.

Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento pelo sítio do evento, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram o denunciado entregando algo a um motorista não identificado, o qual, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se do local, dispensando um objeto sobre o telhado de

um imóvel ali existente.

Realizada a abordagem, com o denunciado foi encontrada 01 (uma) porção de cocaína, a qual trazia consigo para ser entregue ao consumo de terceiros, bem como a quantia de R\$110,00 (cento e dez reais), obtida com o narcotráfico.

Em seguida, arrecadado o objeto dispensado pelo denunciado, os agentes públicos constataram tratar-se de um pacote plástico contendo 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, drogas que ele trazia consigo também para serem entregues ao consumo de terceiros.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 118/124).

A denúncia foi recebida em 28 de maio de 2021 (fls. 128/129).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Memoriais escritos do Ministério Público (fls. 226/233) e da Defensoria Pública (fls. 237/245).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 47/49 e 100/102), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o acusado disse que estava na porta da casa de sua conhecida Cláudia, que é amiga de sua mãe, comendo um lanche e tomando um guaraná, acompanhado de Inara, que é sua amiga. De repente apareceram os policiais e mandaram o acusado sair para rua. Os policiais perguntaram quem havia corrido. O denunciado respondeu que não sabia. Os policiais falaram que ele estava preso. Eles perguntaram se tinha algum acordo, mas não falaram que acordo era, para o acusado não ser preso. Então, os policiais disseram que estava preso, já que não tinha acordo. Tinha na sua posse R\$107,00, que é dinheiro que recebeu da venda de peças de um fiesta de sua propriedade. Não tinha pino de cocaína na sua posse. Não jogou nada sobre o telhado. Não viu os policiais encontrarem droga no telhado. O acusado alega que está sendo perseguido pelos policiais militares por vários anos. Disse que não faz parte de facção criminosa. Esclarece que, momentos antes da chegada dos policiais, um rapaz desconhecido pulou para dentro do quintal da casa vizinha daquela onde o acusado estava conversando com Inara (fls. 08).

Em Juízo, o réu disse que tem 25 anos. É autônomo. Sua avó é de idade e tem problema com sua mãe por ser usuária de drogas. Sua avó estava preocupada. Foi ao bar atrás da sua genitora. O rapaz falou que sua mãe foi para a casa de Claudia. Tomou o café. Passou um moleque correndo. A polícia ingressou na sua casa. Não conhece o rapaz que correu. Os guardas queriam que ele saísse de casa. Falou que

estava atrás da sua mãe. Um policial sumiu da sua vista e voltou com uma porção de cocaína. Tinha noventa reais em seu poder e é decorrente de uma venda de cobre. Falaram que tinha denúncia contra ele. Foi apresentado na delegacia. O delegado o segurou e o prendeu em flagrante. Não estava vendendo drogas. Não pegaram nada em seu poder. Deu muito trabalho aos policiais quando era menor de idade. É perseguido porque abriu um processo contra os guardas. Mexe com sucata de carros velhos. Não pegaram qualquer droga com ele. Claudia estava dentro de casa. Tem antecedentes criminais, mas foi absolvido no tráfico de drogas. A abordagem foi dentro da casa, Claudia presenciou o que aconteceu. Os policiais apareceram com as drogas. Não conversou com qualquer condutor de veículo (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral, a qual incrimina o acusado.

O policial militar João Carlos Oliveira Junior disse que estavam em patrulhamento pelo bairro João Ometto, o local é muito conhecido pela traficância. Passavam com a viatura no local e viram o acusado entregando alguma coisa para um motorista de um Peugeot, de cor preta. Ao ver a viatura, o motorista deixou o local com o veículo e não foi identificado. O denunciado saiu correndo e atirou algo sobre o telhado de uma casa. Foi imediatamente abordado e tinha na sua posse, no bolso da bermuda, 1 pino de cocaína e dinheiro. Indagado, ele alegou que havia jogado maconha sobre aquela casa. Com o uso de uma escada o soldado Cesar subiu e encontrou no telhado um pacote de plástico preto contendo 24 pinos de cocaína, iguais ao encontrado no bolso do denunciado. Não perdeu de vista a ação do réu. Ele tentou entrar numa casa, mas não deu tempo. O que motivou a abordagem foi a atitude típica de comercialização de drogas. Há vários pontos naquele bairro. Viu o réu entregando algo ao condutor. O que ele dispensou foi encontrado. Já o conhecia dos meios policiais, de outras abordagens. Havia informações que ele era traficante. Já havia feito uma abordagem de rotina envolvendo o denunciado. Estava como comandante de equipe. Alan era segurança da equipe. O réu estava sozinho na via pública. Faziam patrulhamento de rotina (mídia).

O policial militar Felipe Cesar Gomes Santos contou que faziam patrulhamento pelo bairro João Ometto. Ao adentrar na rua, viram uma pessoa entregando algo ao condutor de um veículo preto, da marca Peugeot. O automóvel saiu em alta velocidade. O réu estava no ato de entrega, jogou um pacote de cor preta e correu. Estavam bem próximo e viram o que aconteceu. O acusado ingressou na casa. Fizeram a abordagem. Fizeram busca pessoal e localizou um flaconete de cocaína e dinheiro. Ele já era conhecido dos meios policiais. Já havia feito abordagens do acusado pelo envolvimento na traficância ilícita. Indagado, ele disse que nada era dele, que não tinha nada a ver com aquilo. Viram onde caiu o pacote preto e com auxílio de uma escada subiu no telhado e achou um pacote preto. Ao abrir o pacote havia mais 24 flaconetes de cocaína idênticos ao encontrado em poder do autuado. Deram voz de prisão e o conduziram até o distrito policial. Não o perdeu de vista em qualquer momento, os fatos ocorreram numa esquina. Optaram por abordar o réu. Viram movimento de entrega e dispensa de pacote, foi isso que motivou a abordagem, viram o acusado no ato de traficância. Faziam patrulhamento normal. Quando ingressou na rua, viram a situação, não viram de pronto que era o acusado. Só na abordagem é que houve reconhecimento de quem era a pessoa abordada. Não foi possível anotar a placa do automóvel. Desembarcaram e correram atrás dele, tiveram que optar em abordar o réu (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o acusado. Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10)." (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas testemunhas de defesa.

A testemunha Olinda Donizete Mendes disse que é avô do acusado. Foi ouvida como informante. Não presenciou os fatos. Ficou sabendo quando o réu estava no plantão policial. Conhece Claudia de vista, não tem amizade com ela. Seu neto vende carros usados. Foi ela quem o criou. Não sabe a rotina dele, nunca viu nada de estranho. Seu neto fuma maconha e não faz uso de cocaína. Ele garantiu a ela que é inocente. Ela abriu um processo contra alguns policiais numa outra oportunidade, acredita que é perseguição, mas não são contra esses policiais que efetuarão a prisão. Na outra vez houve invasão de domicílio pelos policiais militares, levaram dinheiro do seu parente (mídia).

A testemunha Julia Sobral Lopes contou que é ex-namorada do acusado, o relacionamento durou dois anos. Terminaram o relacionamento há cerca de um mês. Foi ouvida como informante. Estava com a avô do acusado naquele dia. A prisão foi forjada. Não presenciou os fatos. Ele apenas vendia veículos no ferro velho. O réu fumava maconha. Nunca viu ele fazendo uso de cocaína. Após a prisão foram até o distrito policial. O acusado disse que estava no local pois tem um filho lá. Ele fica no local pois o menino mora ali. Sabe que ele mexe com rolo de veículos, ele é rolista. Não sabe quanto ele ganhava por mês, ele vendia muito carro no ferro velho. Já ficou sabendo de outras abordagens, os policiais implicaram com ele. A avô dele está processando uns policiais, acredita que há perseguição policial (mídia).

A testemunha Cláudia Santana Santos disse que é amiga dos parentes do réu. Mora no local dos fatos. O acusado foi atrás da mãe dele. Não viu o momento da prisão. Não viu o encontro de drogas. A mãe do réu é sua amiga e vai de vez em quando. Conhece o acusado há quatro anos. Nunca ouviu falar do envolvimento dele com o tráfico e nem com uso de entorpecentes. Não viu o momento da abordagem. O acusado foi abordado na rua (mídia).

Pois bem.

De acordo com a prova oral colhida, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o réu entregando algo a um motorista não identificado. Ao perceber a presença dos policiais, o acusado fugiu do local,

dispensando um objeto sobre o telhado de um imóvel próximo.

Os militares realizaram a abordagem do acusado e, com ele, localizaram uma porção de cocaína, além da quantia em dinheiro. Arrecadado o objeto dispensado, os agentes públicos verificaram que era pacote plástico contendo 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, idênticas aquela em poder do denunciado. O local da prisão é conhecido como ponto de tráfico.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias da prisão, o encontro de dinheiro sem justificativa, os antecedentes criminais e o local da abordagem, com depoimento incriminador dos agentes públicos, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...)" (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Na esteira da doutrina do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

O depoimento das testemunhas de defesa não afasta a credibilidade e precisão do que

foi narrado pelos agentes públicos em todas as oportunidades em que foram ouvidos. Ademais, o testemunho dos policiais militares vem corroborado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial (Polícia Civil).

Aliás, no caso de acolhimento da versão do acusado (de que o entorpecente foi "plantado"), seria dada razão a tese de que os agentes públicos, de algum modo, adquiriram as drogas, colocaram os entorpecentes no pacote e, por fim, encenaram uma situação de flagrante delito para efetuar a prisão do réu após a sua fuga e perseguição.

A mencionada tese, além de inverossímil, carece de substrato fático probatório mínimo que lhe corrobore. Afinal, se o acusado e as testemunhas por ele arroladas não viram o encontro das drogas, também não viram os guardas "plantando" o material no local.

Para tanto, a testemunha Cláudia mencionou que a abordagem ocorreu fora da sua casa, longe da sua visão. As testemunhas Olinda e Júlia, por sua vez, não presenciaram os fatos criminosos descritos na denúncia, o que reforça a credibilidade do testemunho dos agentes públicos.

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, natureza das drogas apreendidas e das circunstâncias da prisão, com depoimento incriminador dos policiais militares quanto ao tráfico de drogas, de acusado que é reincidente.

Em conformidade com os ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância (...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de

Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consume.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que o acusado tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19. O delito de tráfico foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE

AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)". (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu é reincidente (F.A de fls. 29 - Autos nº 0018720-35.2017.8.26.0320). Desta forma, elevo a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitiva praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a

Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1º6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição quanto ao acusado.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Quanto ao crime de tráfico, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado em razão da reincidência, considerando inclusive o posicionamento do Supremo Tribunal Federal firmado no acórdão proferido no HC nº 118.553/MS.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar SAVIO FELIPE MENDES SOUSA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, no valor, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considera-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como respondeu solto ao processo e compareceu aos atos do processo, poderá recorrer desta em liberdade.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA